

1500236-40.2022.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/09/2022

... causas de aumento e/ou de diminuição de pena - figura do tráfico privilegiado do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Justifico.

O acusado conta com 53 anos de idade e não desfruta de vínculo de trabalho fixo e lícito (fl. 09), estando desempregado há 20 anos (fl. 10), dedicando-se, por conseguinte, ao tráfico. Justifico.

Observe-se ter sido detido em flagrante aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500236-40.2022.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500236-40.2022.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2081945/2022 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 23842115 -

DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2081945 - 01º D.P. AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILO MINEIRO FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

NILO MINEIRO FILHO, devidamente qualificado nos autos (fl. 09), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusado de ter, no dia 24 de março de 2022, por volta das 15h12m, na Rua Santa Catarina, Jardim Brasil, nesta cidade e Comarca, trazido consigo, para

fins de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer forma de disseminação de uso, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, pesando 26,03g, 25 (vinte e cinco) porções de "maconha", pesando 47g e 26 (vinte e seis) porções de "crack", pesando 9,02g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 83/84).

Em audiência de custódia, a prisão flagrancial do averiguado foi convertida em preventiva (fls. 48/50).

A denúncia foi recebida em 18.05.2022 (fl. 85).

Devidamente citado (fl. 120), o acusado, por intermédio de sua D. Defensora, apresentou resposta por escrito à acusação (fls. 90/91), arrolando testemunhas comuns.

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura da fase instrutória (fl. 104), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas das duas testemunhas arroladas em comum, seguindo-se do interrogatório do acusado, tudo pelo sistema audiovisual (cf. atas de fls. 124 e 137).

Em sede de memoriais escritos, o D. Promotor pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, por entender suficientemente provadas a autoria e a materialidade delitiva (fls. 139/141). A D. Defensora, por sua vez, requereu a absolvição, fundamentando-a na deficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, sustentou a tese da desclassificação da imputação original para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, tecendo, ainda, considerações a respeito da pena e do regime prisional (fls. 131/136).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade da infração está devidamente comprovada por meio dos autos de exibição e apreensão (fl. 05) e de constatação provisória (fl. 06), ilustrado com fotos (fls. 34, 35 e 36), pelo comprovante do numerário depositado (fl. 66), bem como e, principalmente, pelos laudos dos exames químicos-toxicológicos realizados nas substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 72/74, 75/77 e 78/80).

Com efeito, os referidos laudos, corroborando o auto de constatação preliminar, confirmaram tratar-se de cocaína, "crack" e "maconha" – com a presença do THC –, substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica listadas na Portaria nº 344/98 – SVS/MS.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Vale lembrar, em primeiro lugar, que o réu foi preso em flagrante, logo após dispensar uma sacola contendo drogas, cuja diversidade, quantidade e forma de acondicionamento, além das circunstâncias fáticas em que estava inserido, indicam a prática da mercancia, razão pela qual a autoria torna-se certa, pois, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho, a prisão em flagrante "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra "Do Flagrante Delito", 1933, p. 25.

De acordo com HÉLIO TORNAGHI, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" ("Curso de Processo Penal", 5ª ed., 49).

Ademais, a análise coligida dos depoimentos colhidos no caderno investigativo e produzidos sob o crivo do contraditório autoriza concluir pela responsabilidade penal do réu. Vejamos.

José Eduardo Rocha, policial militar, relatou que na data dos fatos estava em patrulhamento pelo Jardim Brasil quando, ao ingressar na Rua Santa Catarina, local conhecido como "ponto" de tráfico, avistou NILO conversando com outras pessoas, tendo o réu, ao notar a presença da viatura, alterado seu comportamento e, assustado, saiu andando. Ao ver que seria abordado, jogou uma sacola e saiu correndo, vindo a ser alcançado pelo depoente, em poder de R\$54,00 em dinheiro. A colega do depoente foi quem localizou aquela sacola dispensada, em cujo interior havia porções de "maconha", "crack" e cocaína, em grande quantidade, todas embaladas individualmente. Indagado, NILO confessou informalmente o tráfico.

Gabriela Watanabe Jacobovone, colega de farda, confirmou estar em patrulhamento pelo local, conhecido como "ponto" de venda de drogas, quando avistou NILO em um grupo de pessoas, próximo a uma caçamba de lixo, tendo ele, ao notar a presença da viatura, dispensado uma sacola branca naquela caçamba e saído do meio das pessoas. O colega da depoente desembarcou da viatura e saiu ao encalço do réu, abordando-o, enquanto ela localizou e recuperou a sacola dispensada, identificando em seu interior vários kits de drogas ("maconha", "crack" e cocaína), separados para comercialização. O réu confessou informalmente estar traficando.

Silente na fase policial (fl. 11), interrogado em juízo, NILO alegou que naquela data estava passando pelo local e abriu o "tambor de lixo" para "catar latinhas", quando os policiais se aproximaram. Desconhecia a existência de drogas no interior daquele "tambor de lixo" e não dispensou sacola contendo os entorpecentes apreendidos pelos militares.

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Com efeito, os policiais militares que participaram da ocorrência demonstraram muita segurança em seus relatos, apresentando detalhes substanciais que evidenciam conhecimento do caso e precisão quanto a dinâmica fática.

Em versões harmônicas e que se completaram, atribuíram ao acusado a prática delitiva. Vejamos.

Segundo se depreende da análise dos seus depoimentos, em patrulhamento pelo Jardim Brasil, ao ingressarem na Rua Santa Catarina, avistaram NILO conversando com outras pessoas, tendo ele, ao notar a presença da viatura, esboçado comportamento estranho ao dispensar uma sacola, contendo entorpecentes em seu interior, dentro de uma caçamba que estava próximo a ele, saindo do grupo de pessoas e passado a caminhar em fuga.

Tal reação comportamental anômala foi confirmada por ambas as testemunhas, com a relevante informação da policial Gabriela no sentido de ter visto, seguramente, o réu dispensado uma sacola branca, antes de fugir.

Então, o policial José Eduardo Rocha saiu ao encalço do réu, abordando-o em poder de R\$54,00, enquanto sua colega de farda, motorista da viatura e visualizadora da dispensa pelo réu, se dirigiu até a caçamba de lixo e localizou a sacola branca, em cujo interior havia kits contendo 24 porções de cocaína, 25 porções de "maconha" e 26 porções de "crack", todos embalados individualmente, prontos para comercialização, conforme documentado pelas esclarecedoras fotos de fls. 34, 35 e 36

O réu não apresentou versão convincente, na medida em que relatou estar passando casualmente pelo local e, ao abrir aquele "tambor de lixo" (caçamba) em busca de

latinhas vazias para reciclar, coincidentemente, foi visto pelos policiais, que o abordaram, mas desconhecia, por completo, a existência de drogas no interior.

Ora, não é crível que drogas, naquelas diversidades e quantidades, estivessem jogadas aleatoriamente dentro da caçamba, sem qualquer dono, até porque representam cifras no pernicioso e lucrativo mundo do tráfico.

Outrossim, ele foi visto pela policial Gabriela jogando aquela sacola ao tempo em que saía do meio do grupo de pessoas, antes de iniciar o processo de fuga, sendo, ainda, abordado em poder de R\$54,00.

As circunstâncias fáticas da abordagem, assim como a quantidade de entorpecentes apreendidos e suas formas de acondicionamento, somado ao dinheiro, cancelam que o acusado estava, de fato, trazendo consigo aqueles entorpecentes para comercialização no local, conhecido "ponto" de tráfico.

É certo que a prova oral colhida durante a instrução baseia-se, principalmente nos depoimentos dos policiais que atuaram no caso, mas, vem sendo pacificada a repulsa nas Egrégias Cortes, com lastro do maior quilate na Superior Instância e na Extraordinária em especial, quanto à alegação de imprestabilidade dos depoimentos dos policiais que participam da diligência que culminou com a prisão do acusado.

Tal insistência visa ressuscitar uma velharia nociva prejudicial, em recalcitrar, atribuindo-se ao Estado, a desinteligência de conferir a tais agentes o encargo importantíssimo de coibir o crime, mas, lhes recusar credibilidade para testemunhar.

Assim, concluo serem válidos e plenamente eficazes os depoimentos ofertados pelos policiais, haja vista não contarmos com informações que desabonem ou desprestigiem suas condutas e formas de atuação, tampouco para que atribuíssem ao réu os fatos, incriminando-o maliciosa ou levianamente.

Ademais, não se provou, nem se invocou com concretude, algo em que se baseasse alguma das hipóteses de válido repúdio a ditos testemunhos, a inverossimilhança ou o entrechoque com outras provas.

Outrossim, o fato de o réu não ter sido preso "vendendo" a droga é matéria irrelevante para a configuração do tipo penal em questão, conforme jurisprudência torrencial a respeito, pois o entendimento francamente vencedor é no sentido de que o perigo de dano em tais casos é presumido de modo absoluto, tendo em vista o perfeitamente conhecido efeito lamentável causado pelo traficante de drogas.

Outrossim, já se decidiu que "para formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável à prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente...x (Tribunal de Justiça de Santa Catarina, APL n. 21.376, Rel. Ernani Ribeiro "JC", vol. 53/464)

Sendo assim, as circunstâncias fáticas e a prova oral colhida se mostram suficientes para a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes, não havendo campo jurídico para a pretendida desclassificação para o crime de porte de entorpecentes (artigo 28, caput, da Lei 11.343/06), pena de se afrontar à prova dos autos e a boa atuação dos policiais.

E como também reconhecem os tribunais:

"Não cabe a desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, para o delito de uso indevido, quando ausente a prova, a cargo da defesa, da exclusividade do uso próprio. " (RT 710/325).

Aliás, é sabido que a condição de usuário veiculada – sequer minimamente comprovada –, não exclui, a priori, por si só, a condição de traficante, somente se aplicando a desclassificação quando os elementos permitirem cabal aferição nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal e da análise da sua Certidão de Evento (fls. 96/97), verifico que os apontamentos nela constantes não traduzem maus antecedentes. Da mesma forma, à luz do art. 42 da Lei de Drogas não evidencio a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base poderá permanecer no mínimo legal.

Inexistem agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena – figura do tráfico privilegiado do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Justifico.

O acusado conta com 53 anos de idade e não desfruta de vínculo de trabalho fixo e lícito (fl. 09), estando desempregado há 20 anos (fl. 10), dedicando-se, por conseguinte, ao tráfico. Justifico.

Observe-se ter sido detido em flagrante aos 26.09.2018 na Rua Rondônia, localizada no Jardim Brasil, sendo solto em 27.09.2018 (fl. 96), mas em 05.05.2020 tornou a ser preso flagrante, novamente no mesmo logradouro, sendo, agora, solto em 16.05.2020 (fl. 96).

Nestes autos, foi detido na Rua Santa Catarina, também pertencente ao Jardim Brasil – as ruas são nominadas por Estados do Brasil – em poder de porções de "crack", "maconha" e "cocaína", ou seja, todas as opções comumente procuradas por consumidores de entorpecentes, esgotando as possibilidades de não atender "clientes", já tendo obtido R\$54,00 naquele dia, fruto de vendas anteriores. Em suma, nos últimos quatro anos foram três prisões em flagrantes, todas por tráfico de entorpecentes, sendo ele pessoa conhecida nos meios policiais, segundo relatado pelo policial José Eduardo Rocha.

Anoto que a “dedicação a atividades criminosas” não depende de fatores como a reincidência ou os maus antecedentes.

Nesse sentido:

“(...) Não há ilegalidade na dosimetria da pena, pois, não obstante o paciente seja primário e possuidor de bons antecedentes, o Tribunal estadual afastou a aplicação da causa especial de diminuição, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, as quais o levaram a concluir que o acusado se dedicava a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico (...)” (STJ HC 297406 SP2014/0150910-1, 6ª T., rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 16.10.2014).

Ademais, a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como as circunstâncias do crime, demonstram que o acusado estava envolvido naquela prática, agindo de forma destemida em local público, em plena luz solar, não se tratando de algo eventual.

Ademais: “(...) Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da

redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do delito, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, para afastar a aplicação da minorante (...)" (HC 434.921/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018).

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi.

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

E, no caso em testilha, atento ao seu histórico comportamental e a forma com que se desenvolvia a comercialização das drogas, o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade, não pode ser outro que o inicial FECHADO.

Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social, principalmente no caso do réu preso em flagrante três vezes nos últimos quatro anos, sob a acusação de tráfico. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente desvitaliza a eficácia intimidante da pena, tornando-a inócua.

Pode o juiz determinar o cumprimento da pena em regime fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, §3º, do CP .

NÃO há campo para aplicação do artigo 387, §2º, do CPP, devendo a progressão do regime ser analisada pelo juízo da execução, competente para tanto, na medida em que detém as informações necessárias, sob os prismas objetivo (cálculo de pena) e subjetivo (comportamento carcerário) para enfrentar a questão.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu NILO MINEIRO FILHO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, à razão do mínimo legal, em face da hipossuficiência econômica, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, frente a quantidade de pena imposta (art. 44, I, do CP), bem como em razão desse julgador compartilhar o entendimento no sentido de que o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, não estar preenchido: "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

O réu permaneceu preso durante a instrução processual. Ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, em especial à aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública (art. 312, caput, cc. art. 313, ambos do CPP) – lembrando que o réu foi solto em 15.05.2020 e menos de dois anos depois, ainda respondendo a outro feito criminal, sob idêntica acusação, tornou a delinquir -, agora, frente ao édito condenatório suportado, a ser cumprido em regime prisional mais gravoso, com maior razão, deverá aguardar preso a fase recursal (art. 387, §1º, CPP).

Recomende-se o réu no local em que recolhido.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Com fundamento no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do importe numerário apreendido (fl. 66), em favor da União, expedindo-se o necessário.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução (Súmula nº 716, do STF) e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 18 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA